

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제01절 행정심판의 대상적격>

[예상][12.01-1]처분의 개념과 행정청의 시정권고가 행정심판의 대상인지 여부

《【문제12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 `시정권고`를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음1) 행정심판법 제2조 제1호에서 규정하는 `처분`의 개념과 관련하여, 행정청 A의 `시정권고`가 행정심판의 대상인 처분에 해당하는지 여부를 판례의 입장에 근거하여 논하라.》

<문제12.1의 물음1> 처분의 개념과 행정청 A의 시정권고가 행정심판의 대상인지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A가 甲에게 관계 법령 위반을 이유로 시정권고를 통지하였고, 甲은 해당 권고가 영업 자유를 제한하는 행정심판 대상 처분에 해당한다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판의 대상이 되는 처분의 개념과 비권력적 행정작용인 시정권고가 처분에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정청 A의 시정권고가 행정심판법상 처분에 해당하는지 여부를 논한다.

II. 행정심판의 대상으로서의 처분

1. 처분의 개념

- "행정심판법 제2조 제1호"는 처분을 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용이라고 정의하고 있다. 이는 행정소송법상의 처분 개념과 동일하게 해석되는 것이 일반적이다.

2. 처분성의 판단 기준

- "판례"는 처분인지 여부를 판단함에 있어 그 행위의 성질·태양 및 목적, 응답의무의 존부, 주권자인 국민의 권리의무에 직접 관계되는 것인지 여부, 그리고 당해 행정작용의 실질적 영향력 등을 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단한다. 특히, "최근 판례"는 국민의 권익구제의 폭을 넓히기 위하여 형식적인 법적 효력 유무에만 집착하지 않고 실질적인 불이익 여부를 중시하는 경향이 있다.

III. 시정권고의 행정지도적 성격과 처분성

1. 행정지도와 시정권고의 일반적 성격

- "행정절차법 제2조 제1호"에 따르면 행정지도는 행정기관이 그 직무 범위 안에서 일정한 행정 목적을 달성하기 위하여 특정인에게 일정한 작위 또는 부작위를 권고, 금지, 안내하는 등의 비권력적 사실행위를 말한다. 시정권고는 명칭상 권고의 형식을 띠고 있어 원칙적으로 상대방의 임의적인 협력을 전제로 하므로 법적 구속력이 없는 행정지도에 해당한다.

2. 처분성 인정 여부에 관한 판례의 입장

(1) 원칙적 부정

- "전통적 판례"는 행정지도가 상대방의 자발적 동의를 기초로 하는 것이며 그 자체만으로는 어떠한 법적 권리나 의무를 설정하지 않으므로 처분성이 없다고 보았다. 단순히 사실상의 강제력을 갖는 것만으로는 부족하다는 취지이다.

(2) 예외적 인정(실질적 판단)

- "최근 판례"는 행정지도가 형식상으로는 권고의 형태를 띠더라도 실질적으로 법령의 위반을 전제로 하고, 이를 따르지 않을 경우 후속적인 제재 처분(영업정지, 과태료 부과 등이 예정되어 있어 사실상 강제력을 행사하는 경우에는 처분성을 인정한다. 즉, 당해 행위가 상대방에게 법적 불이익을 수 인하도록 강요하는 효과가 있다면 행정쟁송의 대상으로 삼을 수 있다는 것이다.

(3) 구체적 사례(국가인권위원회 등의 권고)

- 국가인권위원회의 성희롱 결정 및 시정권고와 관련하여 "판례"는 비록 권고의 형식을 취하고 있으나, 당사자의 명예에 직접적인 타격을 가하고 향후 신분상 불이익을 초래할 가능성이 크다는 점을 근거로 처분성을 인정한 바 있다.

IV. 사안의 적용

1. 시정권고의 실질적 영향력 분석

- 사안에서 행정청 A의 시정권고는 관계 법령 위반을 이유로 하고 있다. 법령 위반을 이유로 한 권고는 통상적으로 이를 이행하지 않을 경우 행정청이 강제적인 제재 처분으로 나아갈 것임을 예고하는 전단계 행위로서의 성격을 갖는다.

2. 甲의 영업의 자유 제한 여부

- 甲은 해당 권고가 사실상의 강제력을 가져 영업의 자유를 제한한다고 주장한다. 만약 이 시정권고가 단순한 안내에 그치지 않고, 명단 공개나 후속 제재 처분의 직접적인 요건이 되는 등 甲에게 실질적인 법적 지위의 불안이나 불이익을 초래한다면 행정심판법상 처분으로 보아 다룰 수 있어야 한다.

3. 검토

- "판례"의 법리에 따라 볼 때, 행정청 A의 시정권고가 단순히 권고의 수준을 넘어 상대방에게 법적 의무 이행을 강요하는 실질적 효과를 지닌다면 이는 행정심판의 대상인 처분에 해당한다고 보아야 한다.

V. 결론

- 행정심판의 대상인 처분은 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치는 공권력 행사를 의미한다. 행정청 A의 시정권고는 형식적으로는 비권력적 사실행위인 행정지도에 해당하여 원칙적으로 처분성이 부정되나, "판례"는 그 실질적인 영향력을 고려하여 예외적으로 처분성을 인정하고 있다. 따라서 사안의 시정권고가 법령 위반을 전제로 하여 甲에게 사실상의 복종을 강요하고 불이행 시 제재가 예정되어 있는 등 실질적인 불이익을 주는 작용이라면, 甲은 이에 대하여 행정심판을 청구하여 그 적법성을 다툴 수 있다. 이러한 법리는 행정 작용의 형식이 점차 다양해짐에 따라 국민의 권익이 사각지대에 놓이지 않도록 처분의 개념을 유연하게 해석하려는 현대 행정쟁송법의 흐름과 궤를 같이한다.